

1500896-35.2020.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500896-35.2020.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-35.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Rafael dos Santos Rodrigues e Gleison Sousa Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 35, caput, da LD (fls. 155/157).

Determinou-se o processamento (fls. 175/177).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 223 e 225), apresentou resposta escrita (fls. 281/283 e 286/287). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 299/302) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 331 e 376).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade parcial do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 11/14 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 18/20) e definitivo (fls. 220/219 [LPTox]) e dos laudos periciais telefônicos (fls. 163/166, 167/174, 191/210 [*] e 211/218 [LPTels]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Andrei Donizeti Andrade de Freitas, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "receberam a denúncia de que havia um veículo VW/Gol, na cor branca, onde estavam os indiciados Rafael, vulgo "Pedra" e Gleison, e que eles haviam ido até a cidade de Olímpia para buscarem entorpecentes para venderem em Altair. Mediante a denúncia, a viatura policial deslocou-se para a entrada da cidade, onde alguns minutos depois avistaram o veículo com as características da denúncia e realizaram a abordagem. Ao serem abordados, identificaram quatro ocupantes: Rafael, Gleison, Tiago e Nicolas. Em busca pessoa, foi encontrado na cintura da bermuda de Gleison um tijolo de maconha; com Rafael 10 eppendorf's contendo substância que aparentava ser cocaína, 10 pedras de crack e R\$ 10,00 em dinheiro; sendo que cada um portava um telefone celular; com Tiago e Nicolas, nada de ilícito foi encontrado, apenas estavam com os aparelhos celulares. Informa que o veículo era conduzido por Tiago, e que Nicolas era o passageiro do banco da frente e Rafael e Gleison ocupavam os bancos de trás. Indagados, Gleison confessou a propriedade da droga, porém disse ser para consumo próprio e Rafael, Tiago e Nicolas nada declararam. Por fim, informa que Rafael, vulgo "Pedra" já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive, já houveram outras denúncias de que o mesmo comanda parte do tráfico na cidade de Altair e faz parte do PCC. Tendo em vista a quantidade de entorpecente encontrado, foi dada voz de prisão e conduziram todos até este Plantão Policial". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Gabriel Silva de Paula, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "receberam a denúncia de que havia um veículo VW/Gol, na cor branca, onde estavam os indiciados Rafael, vulgo "Pedra" e Gleison, e que eles haviam ido até a cidade de Olímpia para buscarem entorpecentes para venderem em Altair. Mediante a denúncia, a viatura policial deslocou-se para a entrada da cidade, onde alguns minutos depois avistaram o veículo com as características da denúncia e realizaram a abordagem. Ao serem abordados, identificaram quatro ocupantes: Rafael, Gleison, Tiago e Nicolas. Em busca pessoa, foi encontrado na cintura da bermuda de Gleison um tijolo de maconha; com Rafael 10 eppendorf's contendo substância que aparentava ser cocaína, 10 pedras de crack e R\$ 10,00 em dinheiro; sendo que cada um portava um telefone celular; com Tiago e Nicolas, nada de ilícito foi encontrado, apenas estavam com os aparelhos celulares. Informa que o veículo era conduzido por Tiago, e que Nicolas era o passageiro do banco da frente e Rafael e Gleison ocupavam os bancos de trás. Indagados, Gleison confessou a propriedade da droga, porém disse ser para consumo próprio e Rafael, Tiago e Nicolas nada declararam. Por fim, informa que Rafael, vulgo "Pedra" já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive, já houveram outras denúncias de que o mesmo comanda parte do tráfico na cidade de Altair e faz parte do PCC. Tendo em vista a quantidade de entorpecente

encontrado, foi dada voz de prisão e conduziram todos até este Plantão Policial". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

* Sr. Gleison Sousa Silva:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 07).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava na cidade de Olímpia-SP. Lá, comprou, para consumo pessoal, drogas (maconha). Para retornar, pegou carona com Tiago Gabriel Pirani de Souza. Outra pessoa acompanhava-o (Nicolas Perpetuo Basso). No caminho, o condutor adentrou a cidade de Guaraci-SP. Lá, o coacusado Rafael dos Santos Rodrigues pegou carona também³. Na entrada da cidade de Altair-SP, os membros da Polícia Militar deram ordem de parada. O condutor obedeceu. Abordaram-no. De fato, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas (maconha). Não alegou nada pessoal contra os agentes policiais."

* Sr. Rafael dos Santos Rodrigues:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 09).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava na cidade de Guaraci-SP. Para retornar, pegou carona com Tiago Gabriel Pirani de Souza. Outras pessoas acompanhavam-o (Nicolas Perpetuo Basso e o coacusado Gleison Sousa Silva³). Na entrada da cidade de Altair-SP, os membros da Polícia Militar deram ordem de parada. O condutor obedeceu. Abordaram-no. Não trazia consigo nada de ilícito. Não sabe dizer se alguém trazia consigo drogas. Conduziram-no à Delegacia de Polícia em Barretos-SP. Antes, porém, adentraram a cidade de Guaraci-SP, onde um dos membros da Polícia Militar (Silva Nunes, sic) adentrou o destacamento e retornou com uma sacola de plástico de cor branca (forjamento). Não alegou nada pessoal contra os agentes policiais."

Pois bem.

Do tráfico ilícito de drogas.

Respeitadas as versões dos acusados, entendo que, confrontadas com o quadro de provas produzido, estão absolutamente isoladas (solitárias) e contraditórias (contrapostas) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância

entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto) e Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

No entender deste magistrado, o exercício do direito de permanecer calado (art 5º, LXIII, da CF), perante a autoridade policial, não condiz com o comportamento de quem é, verdadeiramente, inocente (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000243-49.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON TETSUZO NAMBA, V.U., j. 10/07/2020, p. 05 ["Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no 'calor dos acontecimentos', para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime."])).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, os acusados, posto alegar, não provaram.

No entender deste magistrado, ao lado do contexto testemunhado pelos agentes do Estado, descobriu-se, com o afastamento – quebra – do sigilo das comunicações privadas armazenadas no aparelho telefônico celular apreendido com o acusado Rafael dos Santos Rodrigues (fls. 76/77), ao ler as mensagens de texto e de voz encaminhadas e recebidas pelo acusado e pelas pessoas contatadas, comportamentos que, com a intenção de contrair obrigações de compra e venda (animus contrahendi), se referem à circulação de drogas (fls. 204/207 [LPTel]) (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000392-74.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/09/2019, p. 5); sem se esquecer da imagem fotográfica de arma (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500658-30.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.M., j. 04/10/2021, p. 8) (LPTel).

O teor das próprias mensagens, portanto, o contradiz

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD – tipo penal denunciado e processado – não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF – 1ª Turma – HC n. 69.806/GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a

caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Assim, convenço-me que os acusados, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, traziam consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas e sem embalagem fracionária [granel]], indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

De rigor, pois, a condenação dos réus.

Eis o meu convencimento.

Da associação para o tráfico ilícito de drogas.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) – ou querelante – e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua.

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos réus pela prática do contexto fático previsto no art. 35, caput, da LD (associação para o tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

Pontifico.

Nos termos do art. 35, caput, da LD, "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas", configura o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.

O tipo objetivo, vejamos, é "associarem-se" (reunirem-se, juntarem-se, com ânimo de associação, de caráter duradouro e estável) "duas ou mais pessoas" (plurissubjetividade) "para o fim de praticar" (elemento subjetivo específico [finalidade associativa]), "reiteradamente ou não" (habitualidade ou eventualidade

executiva), "qualquer do crimes" apontados com taxatividade pela Lei de Drogas (finalidade associativa).

O que diferencia o crime de associação criminosa específica do tráfico ilícito de drogas (art. 35 da LD) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo (animus) dos sujeitos ativos do crime.

Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era, ou não, eventual, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento dos agentes policiais a respeito da fama deles (odioso critério subjetivo).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não se exige, para a configuração deste crime autônomo, a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (animus manendi, intenção de permanecer, ânimo associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 06), como, por exemplo (verbi gratia), a habitualidade do contato dos réus (periodicidade), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (thema).

Não existe prova suficiente (bastante, necessária) de que se tratava de reunião estável e permanente (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 12/08/2019, p. 11).

Nesse aspecto, esclareço, a denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva, mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte) e, desse modo, o contato (interação) dos réus era meramente ocasional ou episódico.

Não era um verdadeiro pacto associativo, acerto.

Não está evidente a intenção de reiteração delituosa.

Descaracterizada, pois, a associação criminosa específica.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.1.1 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexo de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, ou alheio, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), separadamente.

Do réu Rafael dos Santos Rodrigues

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 09/07/2020

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

9337-89/2014
17/11/2014
24/05/2017
365
20/04/2018
Reincidência
específica

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), início a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente e (iii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 3/6 (três sextos), em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, “enxugadores de gelo”, pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 [“Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênica, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido.”]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO,

V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito

Criminal – Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Quinta Turma – AgrRg no HC n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001146-55.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 06/11/2018, p. 08; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 07; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003231-77.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 28/08/2018; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002297-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 17/10/2019, p. 08; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 06; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000047-59.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 21/02/2019, p. 10; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000206-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 10/10/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0007365-55.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 03/10/2019, p. 08).

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, é significativa a quantidade das drogas apreendidas com a parte ré (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente específica (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP) e cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 3/6 (três sextos), em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e

1.125 (mil e cento e vinte e cinco) dias-multa.

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância agravante da reincidência específica é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501944-97.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Estância Turística de Comarca de Olímpia - Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.U., j. 12/01/2021, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 08; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0008312-75.2013.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 27/07/2020, p. 09 [1/3]; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003985-48.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel.ª Des.ª CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 24/07/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002059-32.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 06/03/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001243-16.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 07/08/2019, p. 03; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003452-89.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO COELHO, V.U., j. 7/02/2019, p. 11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003101-19.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/07/2020, p. 04 [1/3]; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500920-97.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 30/10/2020, p. 04 [1/3]).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.125 (mil e cento e vinte e cinco) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Do réu Gleison Sousa Silva

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 09/07/2020

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

10156-12/2016

13/04/2016

05/07/2017

359

*

Art. 28 da LD

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), início a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente e (iii) a quantidade das drogas são desfavoráveis à parte ré, de modo que, reportando-me às justificativas inicialmente registradas, fixo a pena-base, majorando-a de 3/6 (três sextos), em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Dos antecedentes desconsiderados: A parte ré apresenta dados desabonadores - ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) - da vida pregressa, mas, de acordo com o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500589-32.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA, V.U., j. 19/10/2021, p. 05), a condenação pela prática do crime previsto no art. 28 da LD, posto (apesar de) compreender respeitosamente o contrário, não pode ser considerada, de sorte que não a pondero.

No entender deste magistrado, a estrutura analítica do disposto no art. 28 da LD não se coaduna, deveras (realmente), com o disposto no art. 1º do Decreto-lei n. 3.914/1941 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais), mas, por obra da lei (ope legis), o Poder Legislativo, pela leitura do Capítulo III da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD), tipificou a conduta como crime (com penas diversas da privativa de liberdade) e, por isso e por certo, deve ser tratada.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e

875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância (ato de circulação) pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Para a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da LD, exige-se, cumulativamente, que "o agente seja primário, de bons antecedentes [requisitos positivos], não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa [requisitos negativos]", de modo que, no caso dos autos, falta à parte ré um dos requisitos negativos (não se dedique às atividades criminosas), não se tratando, portanto, de traficante de primeira viagem, a considerar a apreensão de expressiva quantidade de drogas (STJ – 5ª Turma – HC 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10 [71,900g de maconha]; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente ([dado que se refere a uma das partes]) e as circunstâncias não são favoráveis [dado comum às partes].

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 05).

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade [dado comum às partes]), II (reincidência [dado que se refere a uma das partes]) e III (circunstâncias desfavoráveis [dado comum às partes]), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack) (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003045-83.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 29/08/2018; STJ – HC 414347 SP – Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – Dje 21/02/2018)

Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005823-60.2016.8.26.0400 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO COGAN – V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus n. 2078906-82.2014.8.26.0000 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA – V.U., j. 22/05/2014; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400 – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a LÍDIA CONCEIÇÃO – V.U., j. 1º/07/2019, p. 4).

A singularidade é a síntese coletiva.

O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 – Rel.^a Des.^a ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – V.M., j. 05/10/2019, p. 05).

A gravidade do fato sob análise (sub judice) apresenta-se como circunstância distintiva (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1501049-68.2020.8.26.0400 – Rel. Des. SULAIMAN MIGUEL NETO – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia – V.U., j. 10/02/2021, p. 07).

Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP – Câmara Especial – Habeas Corpus Cível n. 2100690-15.2019.8.26.0000 – Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – V.M., j. 30/09/2019, p. 02).

Causa mal irreparável à sociedade.

2.6 Da suspensão condicional da pena

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos [dado comum às partes]), I (reincidência [dado que se refere a uma das partes]) e II (circunstâncias desfavoráveis [dado comum às partes]), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de

liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 261/262 e 337/339), poderá